



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/341/2018, 8/450/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

תובעים	1	נדל עינבר מרקוס נטליה רות, ת.ז. 037696127
	2	מכלין יפה, ת.ז. 055695381
	3	רז גד, ת.ז. 031996531
	4	מרקוס שי, ת.ז. 056501471
	5	שטיין זאב, ת.ז. 014944193
	6	חי אוהד, ת.ז. 027499490
	7	סמש אפרים, ת.ז. 064826092
		באמצעות ב"כ: עו"ד נדב כהן ו/או שני סיון טורג'מן שד המגינים 32, חיפה טל': 04-8339595 פקס: 03-7252843
	נגד	
נתבעים	1	בכר יעל, ת.ז. 065214207
	2	בכר נמרוד
		באמצעות ב"כ: עו"ד צ. הרשקוביץ ואח' שד' פלי"ם 2, חיפה טל': 04-8665999 פקס: 04-8663178
תובעים שכנגד	1	בכר יעל, ת.ז. 065214207
	2	בכר נמרוד
		באמצעות ב"כ: עו"ד צ. הרשקוביץ ואח' שד' פלי"ם 2, חיפה טל': 04-8665999 פקס: 04-8663178
	נגד	
נתבעים שכנגד	1	נדל עינבר מרקוס נטליה רות, ת.ז. 037696127



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/341/2018, 8/450/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- | | |
|---|---|
| 1 | נדל עינבר מרקוס נטליה רות, ת.ז. 037696127 |
| 2 | מכלין יפה, ת.ז. 055695381 |
| 3 | חי אוהד, ת.ז. 027499490 |
| 4 | סמש אפרים, ת.ז. 064826092 |
| 5 | מרקוס שי, ת.ז. 056501471 |

תובעים

באמצעות ב"כ: עו"ד נדב כהן ו/או שני סיון טורג'מן
שד המגינים 32, חיפה
טל': 04-8339595 פקס: 03-7252843

פסק דין

1. מונחות לפני תביעה ותביעה שכנגד. בגדרה של התביעה עתרו התובעים למתן צו מניעה שיאסור על הנתבעים להקים גשרון ופתח כניסה ממנו אל דירתם הממוקמת במפלס הרחוב. התביעה שכנגד נסובה על השאלה האם שורה של הרחבות ושינויים שערכו הנתבעים בדירותיהם וברכוש המשותף התבצעו כדין או שיש להורות לגביהם על השבת המצב לקדמותו.
2. הבית המשותף מושא ההליך מורכב משני מבנים בהם סה"כ 12 דירות. המבנה הקדמי נמצא ברח' פייגין צבי 9, חיפה, והמבנה העורפי מזוהה כרח' פייגין 9א, חיפה. שני המבנים גם יחד מזוהים כחלקה 22 בגוש 10808 (להלן: "הבית/הבית המשותף"). כל הצדדים להליך הם בעלי דירות בבית המשותף. לשם הנוחות יכונה להלן התובעים יחדיו "התובעים", ואילו הנתבעים/תובעים שכנגד "בכר" והנתבעים שכנגד יכונה בהתאמה "נדל", "מיכלין", "חי", "סמש", ו"מרקוס".
3. ביום 15.5.18 ניתן על ידי צו מניעה זמני האוסר על בכר להתחיל בבניית הגשרון עד למתן הכרעה סופית בתיק וזאת מהנימוקים המפורטים בהחלטתי האמורה.
תמצית טענות התביעה-
4. בקשת בכר להקמת הגשרון מבוססת על טענתם כי נתבע מס' 2 הינו נכה, וכי מטרת הגשרון להנגיש את הדירה לצרכיו.
5. השינוי אותו מבקש בכר לבצע אינו עומד בתנאים הקבועים לעניין "התאמה לאדם עם מוגבלות" כמשמעותה בסעיף 59 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין/החוק") הן מהטעם שהנתבע מס' 2 אינו מתגורר בדירה מושא בקשתו, הן מהטעם שלא הוצג בפני הוועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה אישור בעל מקצוע המעיד כי ההתאמה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/341/2018, 8/450/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אכן נדרשת לו לשם מגוריו בדירה והן מהטעם שלבכר חסרות הסכמותיהם של בעלי הדירות ברוב הדרוש לביצוע ההתאמה.

6. ככל שיש בידי בכר הסכמות אזי הן התקבלו במרמה לאחר שבכר הציגו לתובעים מצג שווא ולפיו הם מתעתדים לגור בדירה ובניית הגשרון הינה התאמה הכרחית לנגישות הנתבע לדירה.

7. לחלופין, וככל שמדובר ב"הרחבת דירה", ההסכמות שברשות בכר אינן עומדות בשיעור הנדרש להרחבת דירה מכוח סעיף 72ב(א) לחוק.

8. הקמת הגשרון נועדה להשבחת דירת בכר על גבם ועל חשבונם של התובעים. הדירה נרכשה להשקעה בלבד, ולראיה עם תום שיפוצה היא הועמדה להשכרה ו/או מכירה.

9. הפסיקה קבעה כי הקמת גשרון אינה בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף ואף אינה מהווה הרחבת דירה כמשמעותה בחוק. אשר על כן נדרשת לבכר הסכמתם של כלל בעלי הדירות בבית.

10. לאור זאת יש לקבל את התביעה ולאסור על בכר לבנות גשרון ופתח כניסה לדירתם.

תמצית טענות ההגנה –

11. אין אמת בטענה בדבר מצג שווא בידי בכר. בכר אכן מתכוונים לגור בעתיד בדירה אך מעולם לא התחייבו על המועד בו יעברו לגור בה.

12. 10 מתוך 12 בעלי דירות בבית נתנו הסכמתם להקמת הגשרון. הללו מהווים 83% מבעלי הדירות בבית. התובעים אינם רשאים לחזור בהם מהסכמות שנתנו שעה שהללו גרמו להסתמכות בכר ששינו את מצבם לרעה באופן שהוציאו הוצאות כספיות ניכרות והקדישו זמן רב לשם הגשת תכניות לצורך הוצאת ההיתר התכנוני.

13. הגשרון מתוכנן להבנות מחומרים קלים ושקופים, על אף העלויות הגבוהות הכרוכות בכך, מתוך התחשבות מלאה בבעלי הדירות בבית. גם מיקום הגשרון נועד לצמצם כל פגיעה אפשרית בדירה המצויה תחתיו. ולראיה, מוסדות התכנון דחו את התנגדות התובעים להקמתו בקבעם כי "לא נגרמת כל פגיעה תכנונית למתנגדים מעצם תכנון ומיקום הגשרון המוצע".

14. התקנת הגשרון באוויר אינה גורעת מן הרכוש המשותף ו/או מזכויות הבניה של בעלי הדירות בבית, חומרי אינם מטילים צל או מחשיכים את הרכוש המשותף, ומיקומו אינו פוגע בגישה אל הבית או בשימוש הדיירים ברכוש המשותף.

15. הגשרון מהווה "התאמה לאדם עם מוגבלות" כמשמעה בסעיף 59 לחוק הדורש את הסכמת רוב בעלי הדירות בבית.

16. לחלופין, הגשרון מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף הדורש גם הוא את הסכמת רוב בעלי הדירות בבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/341/2018, 8/450/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. לחלופי חלופין מהווה הגשרון "הרחבת דירה" כמשמעה בסעיף 72(א) לחוק הדורש את הסכמה של 75% מבעלי הדירות בבית.
18. התביעה הוגשה בעקבות סירוב בכר לדרישת תובע מס' 3, להימנע ממכירת הדירה במשך 5 שנים לפחות, ולדרישת תובעת מס' 1, לזכות בפיצויים מוסכמים ללא הוכחת נזק ע"ס 400,000 ₪ באם לא יעברו בכר להתגורר בדירה בתום שנה ממועד הקמת הגשרון.
19. התובעים לא הציגו טעם סביר לחזרתם מהסכמתם, וגם לא הוכיחו את הטענה שחזרו בהם מהסכמתם להקמת הגשרון עוד בטרם הוגשה הבקשה להיתר בניה לוועדה המקומית לתכנון ובניה.
20. הפסיקה קבעה שהסכמה כמותה כהתחייבות חוזית שחזרה ממנה אפשרית רק בהתקיים התנאים לביטול חוזה. עוד נקבע בפסיקה כי המפקחת רשאית לדחות התנגדויות חסרות תום לב.
21. אשר על כן יש לדחות את התביעה ולחייב את התובעים בהוצאות משפט לרבות שכ"ט עו"ד.
- תמצית טענות התביעה שכנגד-
22. בבית המשותף בוצעו לאורך השנים שינויים רבים ברכוש המשותף ובחזיתות המבנה הכוללים: הרחבת דירות, חסימת פתחים וסגירת מרפסות ללא אישורים תכנוניים וללא הסכמות בעלי דירות, תוך פגיעה באסתטיקה של הבית וניצול אחוזי הבניה ברכוש המשותף כדלקמן:
- נתבעת שכנגד מס' 1 (להלן: "נדל") סגרה מרפסות פתוחות בדירתה, אטמה את דלת הכניסה המקורית לדירתה, שיבצה לבני זכוכית בחזית הבניין, התקינה צינור ניקוז לאורך החזית, הוסיפה מסתור כביסה ושינתה את גודל חלונות ופתחי דירתה.
- נתבעת שכנגד מס' 2 (להלן: "מיכלין") סגרה ואטמה את מרפסת דירתה בבלוקים.
- נתבעת שכנגד מס' 3 (להלן: "חיי") פרץ 2 דלתות בחזיתות הבניין והשתלט על שטח משותף מחוץ לדירתו ובתוך כך בנה בחצר המשותפת משטח עץ ומחסן.
- נתבעת שכנגד מס' 4 (להלן: "סמשי") סגר ואטם את מרפסת דירתו בבלוקים.
- נתבעת שכנגד מס' 5 (להלן: "מרקוס") סגרה ואטמה את מרפסת דירתה בבלוקים.
23. עובדות אלו מקימות מניעות כלפי בכר ביחס להקמת הגשרון. לחלופין, בד בבד עם מתן צו מניעה קבוע האוסר על הקמת הגשרון, יש להורות על השבת מצב הדירות הנ"ל לקדמותן בין אם נרכשו במצבן הנוכחי בין אם לאו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/341/2018, 8/450/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. מרבית התובעים מתגוררים במבנה העורפי שברחוב צבי פייגין 9א' כך שדירותיהם לא תושפענה מהקמת הגשר כהוא זה. ולראיה, הוועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה קבעה כי הקמת הגשרון אינה גורעת מן הרכוש המשותף או מזכויות הבניה של בעלי הדירות בבית.

25. עקב התדרדרות מצבו הרפואי של התובע שכנגד יש לקדם את בניית הגשרון ולהנגיש את דירתו.

תמצית טענות ההגנה שכנגד-

26. התביעה שכנגד חסרת שחר, נגועה בשיהוי ובחוסר תום לב ומטרתה אינה אלא סרבול ההליך המשפטי והפעלת לחץ פסול למשיכת התביעה. זאת ועוד, השינויים שנערכו בוצעו בהסכמה וכדין לפני למעלה מעשור ובטרם רכשו בכר את דירתם. חזקה על בכר שידעו גם ידעו את המצב המשפטי הנוהג בבית לאשורו, כפי שיפורט להלן:

נדל עברה להתגורר בדירה שבבעלותה לפני 12 שנה ולא ביצעה בה שינויים מאז ועד היום. לא ידוע מתי ועל ידי מי בוצעו השינויים המפורטים בכתב התביעה שכנגד, וטענות בנוגע אליהם מעולם לא עלו ע"י מי מבעלי דירות הבית.

מכלין רכשה את דירתה לפני למעלה מ-25 שנה. בגין המרפסת בדירתה קיבלה היתר ממוסדות התכנון במהלך שנת 2012. בכר ידעו על השינויים בדירתה בטרם רכשו את דירתם וספק אם היו מביעים את התנגדותם לולא הגשת התביעה נגדם.

חי רכש את דירתו לפני למעלה מ-12 שנה ופתחי היציאה אל משטח העץ בחצר והמחסן שהקים זכו להסכמה מלאה של בעלי הדירות בבית. בנוסף, בימים אלו מגיש חי בקשה למתן היתר בניה לבניית ממ"ד ובתוכנית מוצגים כל השינויים האמורים, והללו קיבלו בשנית את אישור בעלי הדירות בבית. בכר היו ערים לשינויים בטרם רכשו את דירתם ולא התנגדו להם. התנגדותם כעת היא תולדת התביעה נגדם.

על התביעות כנגד סמש להימחק מפאת היעדר יריבות, שכן הוא אינו בעל הדירה המודגמת בתמונה שצורפה לכתב התביעה שכנגד אשר כלפיה מפנים בכר את טענותיהם. יתירה מכך, כל שינוי שבוצע בדירה, ככל שבוצע, נעשה כדין ובהסכמה מלאה של כל בעלי הדירות בבית טרם שרכשו בכר את דירתם.

ברשות מרקוס מצויים אישורים תכנוניים והסכמות דיירים כנדרש עפ"י כל דין.

החליכים בתיק-

27. ביום 15.5.18 ניתן על ידי צו מניעה ארעי שאסר על בכר להתחיל בבניה, וביום 29.5.18 נקבע התיק לדיון במעמד שני הצדדים.

28. כן ציין בא כוח בכר כי הגנתם של בכר מושתת על שלושה אדנים: האחד, התאמה לאדם עם מוגבלות לפי סעיף 59 לחוק המקרקעין - צופה פני עתיד. השני, יש לראות בהקמת הגשרון הרחבת דירה שנדרשת לה הסכמה של 75% מבעלי הדירות שצמודים להם שני שלישים מהרכוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/341/2018, 8/450/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף, ולבכר קיימת הסכמה בשיעור העולה על השיעור הנדרש. השלישי, נוכח העובדה שהגשרון אינו פוגע ברכוש המשותף יש לראות בו שימוש סביר ברכוש המשותף.

29. בדיוני ההוכחות שהתקיימו ביום 26.6.19 וביום 17.12.19 העידו מטעם התביעה: נדל, חי, סמש ומרקוס, ומטעם ההגנה העיד נתבע מס' 2.

30. הצדדים סיכמו טענותיהם בע"פ וכעת נותר לי להכריע בסוגיות שבמחלוקת.

דיון והכרעה-

31. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה ולדחות את מרבית התביעה שכנגד. הכל כפי שיפורט להלן.

32. הקמת הגשרון והפתח האם מהווים שימוש סביר ברכוש המשותף - לא מצאתי לקבל את טענת בכר כי הקמת גשרון שיחבר בין הרחוב לדירה ופתיחת פתח כניסה ממנו לדירה מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף.

33. בפסיקה אמנם נקבע כי בעל דירה רשאי לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף ללא צורך בקבלת הסכמה של יתר בעלי הדירות בבית לכך, ואולם, דעתי היא כי הפעולות אותן מבקש בכר לבצע אינן בבחינת "שימוש" כפי שפורש בפסיקה. המדובר בשינויים צמיתים, זאת להבדיל משימושים, אותם מבקש לבצע ברכוש המשותף המחייבים אף קבלת היתר בניה, וראו בעניין את הדברים שנקבעו בע"א (מחוזי ת"א) 1251/00, 2646/00 סרי נ' בן ארצי, פס' 10 (פורסם בנבו, 26.3.2002):

"... בנייתו של מבנה על ידי אחד הדיירים בלבד לא תתאפשר במסגרת הניהול או השימוש הרגילים של חצר המהווה קניין משותף. . . לפיכך אין לראות ביציקת הבטון בחצר משום שימוש סביר בשטח המשותף שכן יש בה משום שלילה לצמיתות של זכות השימוש. . . מיתר בעלי הדירות בבית."

34. אין בידי להלום, שניתן לראות בבניית פתח יציאה מהדירה וגשרון קבוע נישא באוויר, המגשר בין הרחוב לבית, שימוש סביר כהגדרתו בפסיקה. עסקינן בשינויים פיסיים וקבועים של הרכוש המשותף שאינם עולים כדי שימוש ברכוש המשותף.

הקמת הגשרון והפתח האם הרחבת דירה-

35. סעיף 71ב (א) לחוק המקרקעין שעניינו הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לצורך הרחבת דירה קובע כדלהלן:

71ב. (א) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/341/2018, 8/450/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות.

(ב) לא תתקבל החלטה כאמור בסעיף קטן (א) אם יש בה כדי לפגוע בזכויות בניה יחסיות של כל בעל דירה להרחבה לפי סימן זה.

(ג) בעל דירה שהורחבה ייראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין".

36. "הרחבה" הוגדרה בסעיף 71א לחוק המקרקעין כ- "הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת תוקף".

37. בפסיקה נקבע כי לצורך ביצוע הרחבת דירה בהתאם לסעיף 71ב לחוק, נדרשת הסכמה מפורשת. יפים לעניין זה דבריה של כב' השופטת דורנר בע"א 5043/96 גלמן נ' הררי-רפול, פ"ד נד(3), 394 (2000) 389 (להלן: "פס"ד גלמן"):

"גישה פרשנית זו אף מתחייבת מן הפסיקה המשקפת מדיניות משפטית המגנה על בעל דירה בבית המשותף, ושלפיה ויתור על זכות הנובעת מבעלותו בדירה בבית משותף בין שהמדובר בזכות ברכוש המשותף ובין שהמדובר בהסכמה לבניה (דהיינו ויתור על אחוזי הבניה) חייב להיות מפורש".

38. בע"א 1415/00 אברהם נ' אזרד פסקה 8 (לא פורסם, 4.7.01) (להלן: "פרשת אזרד") התייחס בית המשפט באופן ספציפי לשאלה האם ניתן לראות בבניית מרפסת "הרחבה" כמשמעותה בסעיף 71א לחוק המקרקעין וכך נקבע בפסק הדין:

"...אין רמז לכך שהרחבה לא יכולה להתייחס לבניית מרפסת שהרי כבר נפסק שמרפסת היא חלק מדירה. בע"א 190/84 דיבון נ' הממונה על המרשם, פ"ד תשמ"ה(ב), 265, פסק כב' הנשיא זילר, כי אין מניעה שדירה תכלול גם שטח בלתי מקורה. (לדיון בפסיקה זו ראו: י. ויסמן, בספרו הנ"ל, עמ' 384-379). באופן דומה הבהיר זאת גם המלומד אייזנשטיין, בקובעו: "במונח הרחבה, נכללת כל הגדלה מהווה המשך טבעי של הדירה...ההרחבה יכולה להיות גם אופקית, כגון בניית מרפסת או סגירתה...התנאי להרחבה הוא כי ההרחבה תהא מתוך דירת המבקש..."

ואולם, תנאי להיות הבניה "הרחבה", עליה חל סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, הוא שמדובר על הגדלה של שטח הדירה, שכן הרחבת דירה נועדה להקל על מצוקת הדיור ולא להצמיד לדירה שטחים מהרכוש המשותף, ראו אריה אייזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי: בתים משותפים, 223 (2001) (להלן: "אייזנשטיין").

לדידי, הקמת הגשרון אינה מקיימת את תכליתו של החוק, שכן היא לא נועדה להקל על מצוקת הדיור, והיא אינה מהווה הגדלה של שטח הדירה, אלא נועדה אך להקל או לאפשר גישה נגישה יותר לדירת בכר. הקמת הגשרון מהווה שינוי ברכוש המשותף שאינו עולה כדי הרחבה של הדירה, ומשכך, היא איננה נכללת בגדר הוראות סימן ג' 1 לפרק ו' לחוק המקרקעין (תיקון 18 לחוק), ולא חל עליה הרוב המופחת שנקבע בסעיף זה.

מהו, אפוא, הרוב הדרוש להקמת הגשרון ?



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/341/2018, 8/450/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

39. היות שהגשרון נועד לשרת את דירת בכר בלבד, והוא כרוך בבינוי ושינוי צורה של הרכוש המשותף, הרי שמדובר בשימוש ייחודי ברכוש המשותף אשר מחייב קבלת הסכמה של כל בעלי הדירות. אפנה בעניין לדברים שנקבעו בעש"א 18-10-48941-10 דין נ' אילון, פסקאות 5 ו-7 (פורסם בנבו, 24.9.2019) (להלן: "פס"ד דין") לעניין שיעור הרוב הדרוש לבניית גשרון:

"בעניין הגשרון קבע המפקח בפסק-דין, שלא מדובר בהרחבת דירה, אלא בפעולת בינוי ברכוש המשותף המחייבת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית. אף מבלי להידרש לשאלה אם היה מקום לכך שבמסגרת הערעור יעלו המערערים טענות חדשות אשר לא נטענו לפני המפקח, הרי שלגוף העניין מצאנו כי לא נפלה שגגה בקביעתו בעניין הגשרון...."

הגשרון שבנו המערערים ממפלס הכביש, אשר נועד לשמש דרך גישה אל דירותיהם, אינו בגדר "הרחבה" של דירה, ואף אינו יכול להיחשב בשום צורה המשך של הדירות של המערערים או הגדלת שטחן.

אכן ניתנה למערערים הסכמת הרוב הדרוש של דיירי הבית המשותף, כנדרש על-פי סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין וכפי שאף קבע המפקח בפסק-דין, אך להסכמה זו אין כל רלוונטיות לעניין בניית הגשרון. כאמור לעיל, הסכמת רוב הדיירים לגבי הוצאת חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, יכולה להינתן רק לשם בניה "שמטרתה הרחבת אותה דירה", מה שאין כן בענין הגשרון שאינו הרחבה של דירה".

40. מוצאת אני לאמץ את קביעתו של בית המשפט המחוזי בפס"ד דין המאמצת את עמדת המפקח בעניין ולקבוע כי לבכר דרושה הסכמה של 100% מבעלי הדירות בבית לצורך בניית הגשרון. אין חולק כי הסכמה כאמור אינה נתונה להם, שכן אף לשיטתם קיימת להם הסכמה בשיעור של 10 מ-12 בעלי הדירות בבית בלבד.

41. לאור האמור, אין די בהסכמות שקיבלו בכר בכדי לאשר את הקמת הפתח והגשרון.

42. לאור מסקנתי זו לא מצאתי להידרש לשאלה האם רשאים היו התובעים לחזור בהם מהסכמותיהם בטענה שהללו ניתנו בעקבות מצג שווא שהציגו להם בכר כי הם עוברים לגור בבית מיד לאחר שתבנה ההתאמה לנתבע שהוא אדם עם מוגבלות.

האם ניתן לאשר את הגשרון והפתח כהתאמה לאדם עם מוגבלות-

43. חלופה שלישית לה טענו בכר היא שבניית הגשרון ופתח הכניסה לדירה נחוצים לנתבע מסי' 2, בהיותו אדם עם מוגבלות, לצורך הנגשת דירתו.

44. בסעיף 59 לחוק המקרקעין נקבעו התנאים שבהתקיימם רשאי בעל דירה לבצע התאמה ברכוש המשותף. אביא להלן את הסעיף ככתבו וכלשונו:

"9(ג) בעל דירה שהוא, שבן משפחתו המתגורר עמו, או שאדם השוכר ממנו את הדירה, הוא אדם עם מוגבלות, רשאי, בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ד), לבצע התאמה ברכוש המשותף כמפורט בחלקים א' עד ג' לתוספת השנייה (להלן - התאמה), ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(1) היה ביצוע ההתאמה עבודה או שימוש הטעונים היתר לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 7 - בעל הדירה קיבל היתר לפי החוק האמור ומילא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/341/2018, 8/450/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אחר תנאי ההיתר;
(2) רופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק אישר בחתימתו במסמך הערוך לפי הטופס שבחלק ד' לתוספת השנייה, כי ביצוע התאמה, כפי שפירט דרוש לאדם עם המוגבלות, בשל מוגבלותו, לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה;
(3) ההתאמה אינה מונעת מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר, וההתאמה תיעשה בדרך שתצמצם ככל האפשר את הפגיעה בבעלי הדירות האחרים ובחזות הבית;
(4) ביצוע ההתאמה ייעשה על חשבון בעל הדירה; ...
(ג)(2) ביצוע התאמה מבין ההתאמות המנויות בחלק ב' שבתוספת השנייה טעון הסכמת רוב בעלי הדירות בבית המשותף;
(ד) מצא המפקח כי בעל דירה התנגד מטעמים בלתי סבירים לביצוע ההתאמה או התנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים, והחליט להרשות את ביצוע ההתאמה, תבוא החלטתו במקום הסכמתו של בעל אותה דירה לעניין סעיף קטן ג(2) ו-(3)."

45. התוספת השנייה שבחוק המקרקעין מונה את ההתאמות אותן ניתן לבצע כהתאמות לאדם עם מוגבלות. בחלק ב' לתוספת מנויות ההתאמות אשר טעונות הסכמת רוב בעלי הדירות בבית, ובכללן פתיחת פתח כניסה לדירה והוספת שביל גישה וכבש.
46. בסעיף 1 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל-1970 הוגדר "כבש" – "מישור משופע קבוע המקשר בין שני מפלסים ושיפועו גדול מ-5%".
47. לדידי, בין אם נראה בגשרון שביל גישה חדש לדירה ובין אם נראה בו כבש, שני השינויים נמנים על ההתאמות המפורטות בחלק ב' לתוספת השנייה שבחוק המקרקעין עליהן חל סעיף 59ג לחוק.
48. הוראת החוק קובעת כי כאשר בעל דירה, בן-משפחתו המתגורר עמו, או אדם השוכר ממנו את הדירה, הוא אדם עם מוגבלות, רשאי בעל הדירה, בכפוף לתנאי הסעיף, לבצע התאמה ברכוש המשותף, ונקבע בסעיף כי יש להוכיח היתכנות קבלת היתר בניה, נדרש אישור רופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק על טופס בנוסח המהווה אף הוא חלק מהחוק, וכי ביצוע ההתאמה דרוש לאדם עם המוגבלות בשל מוגבלותו לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה.
49. בהתאם לסעיף 59ג(ב)(3) לחוק יש להוכיח גם כי ההתאמה אינה מונעת מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר, וכן כי תוסב פגיעה מצומצמת ככל האפשר לבעלי הדירות האחרים ולחזות הבית.
50. גם מקום בו מבקש ההתאמה נעדר את הרוב הדרוש, הקנה המחוקק למפקח על רישום מקרקעין בסעיף 59ג(ד) את הסמכות להתיר את ביצוע ההתאמה (חרף היעדר הרוב הדרוש) אם מצא כי בעל דירה התנגד להתאמה מטעמים בלתי סבירים או התנה הסכמתו בתנאים בלתי סבירים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/341/2018, 8/450/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

51. את הוראת סעיף 59ג לעיל יש לפרש לאורן של המטרות הברורות אשר הוגדרו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות"), בזו הלשון:
- "חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו".**
52. בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הוגדר "אדם עם מוגבלות" – **"אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים".**
53. החוק חוסה תחת כנפו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו שבסעיפים 1-2 שבו מעוגנת ההגנה על כבוד האדם וחירותו, חייו וגופו.
54. ואם לא די בכך, הרי שכב' הנשיא ברק (כתוארו דאז) קבע בבג"צ 7081/93 בוצר נ' מועצה מקומית "מכבים-רעות", פ"ד (1) 19, 26 (1996), בהתייחסו להסדרים שונים בדיון הקשורים עם אדם עם מוגבלות, לאמור:
- "מטרת ההסדרים אינה להיטיב עמו (עם הנכה) בבדידותו אלא לשלבו ... במרקם הרגיל של חיי החברה".**
55. עסקינן, אם כן, בתחרות בין הצורך להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, תוך מתן מענה הולם לצרכיו המיוחדים, ובמקרה זה הנגישות לביתו, לבין זכותם הקניינית של יתר בעלי הדירות בבית - התובעים, להתנגד ולהגן על זכותם הקניינית ברכוש המשותף שלא תוסב לו פגיעה כמשמעותה בסעיף 2 לתקנון המצוי. יש לבחון את האיזון הראוי בין זכויות אלו תוך שימת דגש האם קיימות אלטרנטיבות פוגעניות פחות.
56. אבחן להלן את התקיימותם של התנאים המצטברים המפורטים בסעיף 59ג(ב) לחוק המקרקעין.
57. אקדים אחרית לראשית ואבחן את התקיימותם של התנאים המפורטים בס"ק (1), (3)-(4) לסעיף 59ג(ב) לחוק טרם בחינת התקיימותו של ס"ק (2). כפי שיפורט להלן שוכנעתי כי הללו מתקיימים.
58. הקמת הגשרון טעונה היתר לפי חוק התכנון והבניה, בתשכ"ה-1965, ובכך המציאו אישור בתנאים של הוועדה המקומית לתכנון ובניה הממלא אחר התנאי המפורט בס"ק (1) שבסעיף 59ג(ב), צורף כנספח ד' לתצהיר בכר.
59. באשר לתנאי ולפיו יש לוודא כי ההתאמה אינה מונעת מבעלי דירות אחרים בבית להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר, וכי היא נעשית בדרך שמצמצמת ככל האפשר את הפגיעה בבעלי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/341/2018, 8/450/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדירות האחרים ובחזות הבית, הדעת נותנת כי הקמת גשר מעל דירת נדל עלולה לגרום לדירה זו לפגיעה. ואולם, התנאי האמור בסעיף מאפשר ביצוע של התאמות חרף ההיתכנות שלהן לגרום לפגיעה בבעלי דירות בבית, תוך שנקבע כי יש לוודא שההתאמה נעשית בדרך **שמצמצמת** ככל האפשר פגיעה בבעלי דירות אחרים או בחזות הבית. מצמצמת משמעה פוגעת במינימום ההכרחי.

60. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי בראיות שהוגשו לי שוכנעתי כי אמנם הגשר יגרום לפגיעה כלשהי בדירת נדל, אך היא נעשית באופן שמצמצם פגיעה זו ככל האפשר. יעידו על כך ההסכמות שנתנו 10 מ-12 בעלי דירות בבית לבניה, עת סברו כי בכך מתעתדים לגור בבית, ויעיד על כך כתב ההתחייבות שנחתם בין בכר לבין נדל, צורף כנספח ב' לתצהיר בכר, בו הגיעו בכר ונדל להסכם כתוב וחתום ביניהם אודות החומרים מהם יבנה הגשר, מיקומו וגובה הפיצוי שישולם לנדל במקרה הפרה, הכל במטרה לצמצם את הפגיעה האפשרית בנדל. לכך יש להוסיף את העובדה שנדל העידה בעמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 26.6.19 שורות 29-31 כי ביצוע ההתאמה נעשה באופן שמצמצם את הפגיעה למינימום. וזו עדותה בעניין: **"הדירה שלי ממוקמת מתחת לגשר, אנחנו עשינו מתוך הבנה שזה בן אדם נכה שבא לגור בבניין עשינו את מירב המאמצים למצוא מיקום לגשר שיפריע במינימום לדירה שלנו ועדיין יאפשר נגישות מקסימלית ונוחיות מקסימלית לאדון בכר להיכנס לדירה שלו... עשינו פה את המקסימום לבוא לקראתו וכשגילינו שהדירה בכלל לא הולכת לשמש אותו הרגשנו...". הייתי ממשיכה את הציטוט חשוב להבין מה היה שם** אף לשיטתה של נדל הגשר תוכנן להיבנות באופן שמצמצם את ההפרעה לדירתה למינימום. לאור האמור, תנאי זה מתקיים.

61. לעניין התקיימותו של התנאי האמור בס"ק (4), אין מחלוקת על כך שביצוע ההתאמה מתוכנן היה להיעשות על חשבון בכר.

62. באשר לתנאי האמור בס"ק (2), לא שוכנעתי כי תנאי זה מתמלא שכן בכר לא המציא אישור של רופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק ערוך לפי הטופס שבחלק ד' לתוספת השנייה, כי ביצוע ההתאמה דרוש לנתבע מס' 2 בשל מוגבלותו לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירה. העובדה שלנתבע מס' 2 קיימים אחוזי נכות זמניים או קבועים מהמוסד לביטוח לאומי אינה פוטרת אותו מהמצאת הטופס האמור ואינה ממלאת אחר תנאי זה בסעיף.

ויוטעם, כפי שעולה מהטופס האמור, תפקידם של הרופא, הפיזיותרפיסט או המרפא בעיסוק אינו רק לקבוע כי המבקש הוא אדם עם מוגבלות, אלא לבחון את ההתאמה המבוקשת ולאשר כי התאמה זו היא ההתאמה הנדרשת לו לצורך נגישות בטוחה ועצמאית לדירתו, ולצורך כך עליהם לבקר בבית ולבחון את נתוניו. האישור האמור הוא תנאי בלתי ניתן להחלת יתר הוראות סעיף 59 על הנתבעים.

וראו בעניין את דברי ב"כ בכר בעמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 26.6.19 שורות 9-12: **"בתצהיר שלך את מתייחסת לעובדה לדוגמה בסעיף 18 לעובדה שהנתבעים לא הציגו לוועדה המקומית אישור רופא, אני אומר לך שאישור כזה מעולם לא הוצג לוועדה מכיוון שתיק הבקשה לבניית הגשר לא הוגש על רקע או על בסיס בקשה להקלה להיתר לנכה אלא כבקשה רגילה לבניית רגילה...".** וראו גם עדות הנתבע בעניין בעמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 17.12.19 שורות 9-10.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/341/2018, 8/450/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

63. יתירה מכך, הנתבע מס' 2 אישר כי אינו גר בדירה ואף סירב להתחייב לגבי המועד בו יעבור לגור בה. אינני סבורה כי תנאי להחלתו של סעיף 59 לחוק המקרקעין הוא מגוריו של האדם עם המוגבלות בדירה במועד הגשת הבקשה להיתר בניה, לטעמי נכון להחיל את הוראות הסעיף גם על התאמות שמבוקש לבצע ברכוש המשותף לצורך הכשרת דירה והתאמתה למגוריו של אדם עם מוגבלות שמתעתד לגור בה מיד לאחר שתוכשר. ואולם, תנאי הוא שהדירה הרלבנטית נועדה לשמש למגורי הנתבעים או אדם עם מוגבלות המתגורר עמם. בנסיבות תיק זה לא שוכנעתי כי בכך תכננו להיכנס מיד בתום השיפוץ או במועד כלשהו אחר לגור בדירה. יעידו על כך הדברים הבאים:

ראשית, בתכתובת המיילים שהוחלפה בין נתבעת מס' 1 לבין נדל כתבה נדל לנתבעת: "מתשובתך לא ניתן להבין מתי בכוונתכם לעבור לגור בדירה אם בכלל. אשמח לשתף פעולה אם תמצאו תצהיר מאושר ע"י עו"ד שבמידה ומסיבות כאלו ואחרות נמרוז לא יעבור להתגורר בדירה בתוך שנה מהיום הגשר יפורק ותחזירו את המצב לקדמותו ובמקרה שלא תעשו כן תפצו אותנו בסכום של 400,000 ₪ ללא שום צורך בהוכחת נזק מצידנו". בכך במענה הכחישו את הטענה כי אין בדעתם לעבור לגור בבית, אך סרבו להתחייב לגבי מועד כניסתם לדירה. בהינתן שבכך עתידים היו להיכנס לגור בדירה לאחר ביצוע ההתאמות לא ברור מדוע סירבו להתחייב כאמור. יודגש כי די היה בציון מועד כללי (שנה/חודש).

שנית, בדיון שהתקיים בתיק הבהיר בא כוח בכר כי על אף שהנתבע מס' 2 נכה צה"ל בעל תעודת נכה "מעולם לא הוצג מצג שמר בכך מתעתד מחר לגור בדירה או שנה לגור בדירה", ראו עמ' 2 לפרוטוקול הדיון מיום 29.5.18 שורות 18-11 וכן בשורה 46.

שלישית, מחומר הראיות עלה כי בכך פרסמו את הדירה למכירה במשך חודשים רבים החל מחודש 9/17 ולמצער עד סוף חודש 5/18, הפרסומים צורפו כנספח ב' לתצהיר נדל. בכך אישר בעדותו, בעמ' 2 לפרוטוקול הדיון מיום 17.12.19, כי הדירה פורסמה למכירה ב-9/17. עדות הנתבע מס' 2 בנוגע לנסיבות שהביאו לפרסומה לא הייתה מהימנה, ולא שוכנעתי כי פרסומה נבע רק מ"המרורים שאכלנו מהגב' נטלי במשך כל תקופת השיפוץ" (ראו עדותו בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 7-3), שכן לו אכן זו הייתה סיבת פרסומה למכירה של הדירה, מתבקש היה שהדירה תפורסם בהתאם למצבה במועד הפרסום (ללא גשרון), ולא כפי שפורסמה במודעת הפרסום ככוללת "גשר ישר לדירה, ללא אף מדרגת גישה".

64. בכך אמנם טענו בפניי כי הגשרון נועד להתאים את הדירה לכניסה עתידית של הנתבע מס' 2 לדירה, אך בעדותו ובכל המסמכים שהוגשו לתיק לא נקב הנתבע בכל תאריך יעד בו בדעתו לעבור לגור בדירה. בנסיבות אלו, לא שוכנעתי כי בכך התכוונו או מתכוונים לעבור לגור בדירה, ומשכך, דעתי היא כי התנאי האמור בס"ק (2) לסעיף 59ג(ב) לחוק אינו מתקיים.

65. לאור האמור, משלא מתמלאים כל התנאים המפורטים בסעיף 59ג(ב) לחוק המקרקעין, לא ניתן להחיל על הבניה את הוראות סעיף 59 לחוק המקרקעין ולא ניתן לאשר את הקמת הגשרון ופתיחת הפתח כהתאמות לאדם עם מוגבלות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/341/2018, 8/450/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

66. טרם סיום פרק זה אציין כי לא מן הנמנע שבעתיד בכר יהיו רשאים לחדש בקשתם להיתר בנייה להקמת הפתח והגשרון ככל שימלאו אחר מלוא התנאים המפורטים בסעיף 59 לחוק.

התביעה שכנגד-

67. תובע שכנגד מס' 2 הפנה בתצהירו לשינויים שבוצעו בדירות הנתבעים שכנגד הכוללים: ביצוע שינויים בקירות חיצוניים, לרבות: פתיחת דלת, הוספת לבני זכוכית בקיר חיצוני, הוספת מסתור כביסה, שינוי גודל חלונות, התקנת משטח דק והצבת מחסן עץ בחצר וסגירת מרפסות. כראיה לאמור צורפו לתצהירו כנספחים ח' ו-יד' תמונות המדגימות את השינויים שבוצעו. לטענתו, שינויים אלו בוצעו ללא היתר בניה וללא הסכמת האסיפה הכללית.

68. כפי שפורט בהרחבה בפרק "תמצית טענות ההגנה שכנגד" לעיל, כל הנתבעים שכנגד טענו כי השינויים בוצעו למצער לפני 12 שנים בהתאם להיתרי בניה כדן, הם לא נעשו על ידם אלא ע"י בעליהם הקודמים של דירותיהם, בהסכמת כל בעלי הדירות בבית, הראיה שאף לא אחד מבעלי הדירות בבית, לרבות בכר, לא הלינו מעולם על השינויים. אבחן להלן טענות אלו.

69. אקדים ואציין כי בכל הקשור לטענות כי השינויים שבוצעו נעדרים היתר בניה, הרי שטענות בדבר הפרת הוראות דיני התכנון והבניה ודיני נזיקין אינן מצויות בגדר סמכותי העניינית, ועל כן אמנע מלהתייחס להפרה לכאורה של דיני התכנון והבניה עצמם וכן אמנע מלהתייחס לטענה הנזיקית בדבר הפרת חובה חקוקה בהקשר זה. לאור האמור, לא תיבחן על ידי טענת בכר ולפיה השינויים שבוצעו נעדרים היתר בניה.

70. אתייחס להלן להיבט הקנייני בנוגע לשינויים שבוצעו..

71. בת"א (מחוזי י-ם) 18410/90 בן דוד נ' קסיס, עמ' 4 לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה (פורסם בנבו, 9.6.1996) (להלן: "פס"ד בן דוד") הבחין בית המשפט בין סוגי שינויים שמבוצעים ברכוש המשותף והתייחס לשיעור ההסכמות הנדרש לכל אחד מהם. האמור יפה גם לענייננו ועל כן אביאהו כלשוננו:

"חוק המקרקעין והתקנון המצוי יוצרים אבחנה ברורה בין שני עניינים אלה הנוגעים לרכוש המשותף:

1. עניינים שמטיבם עומדים להכרעה באספה הכללית של הדיירים על פי מנגנון קבלת החלטות כפי שנקבע בתקנון.

2. עניינים שאינם נושא להכרעה באספה הכללית אלא מותנים בהסכמה של כל בעל זכויות ברכוש המשותף או חלקם.

האבחנה בין שני סוגי עניינים אלה אינה תמיד קלה, אך מהמשקל המצטבר של הוראות הדין וקביעות הפסיקה, ניתן להסיק את המסקנות הבאות:

א. העניינים המסורים להכרעת האספה הכללית ברוב קולות הם:

(1) עניינים הנוגעים לדרך ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו (סעיף 5(א) לתקנון המצוי).

(2) עשיית שינויים או תיקונים על ידי בעל דירה בדירתו, הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו. ולעניין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" פירושה גם פגיעה בחזות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/341/2018, 8/450/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בגמר הבניה (סעיף 2(א) לתקנון המצוי). החלטות אספה כללית מתקבלות ברוב דעות (סעיף 12(א) לתקנון).

כך נפסק, למשל, כי פריצת קיר חיצוני של בית משותף לצורך התקנת מזגן אויר נכנסת למסגרת סעיף 12(א) הנ"ל ומחייבת החלטה של האספה הכללית (ע"א 93/84 קדמי נ' קווין, פ"ד מ' (1) 724).

ב. לעומת זאת, ישנן פעולות המשפיעות על הרכוש המשותף המצריכות הסכמה של כל אחד מהדיירים נוכח הפגיעה הכרוכה בהן בזכויות הקנייניות, ולגבי אלה אין די בהחלטת האספה כללית. כך, למשל, דייר המייחד לעצמו שטח ברכוש המשותף, רואים בכך פגיעה בעלת אופי קנייני הנוגסת בזכויות הקנייניות של שאר בעלי הזכויות ברכוש המשותף וכשרות הפעולה מותנית, על כן, בהסכמת כל הדיירים (ראה סעיף 62 (א) לחוק המקרקעין; וסעיף 12 (ב) לתקנון המצוי).

הפעולות הבאות הוכרו כנמנות על סוג זה של עניינים: הקמת מבנה על רכוש משותף לשימוש יחודי של דייר, בניית מרפסת או תוספת למרפסת קיימת, וכן סגירת מרפסת. הוא הדין בפגיעה בזכות שימוש של הדיירים בגג על ידי סגירת פתח כניסה לגג (ויסמן "יחד ולחוד בבית המשותף", משפטים ט"ז 170; ע"א 93/81 אליאס נ' שיפר, פ"ד ל"ז (2) 444, 448; ע"א 429/80 גרפינקל נ' ארליך, פ"ד ל"ז (4) 141; ע"א 381/66 לוי נ' לינקביץ, פ"ד כ' (4) 557; רע"א 698/85 בן צור נ' שושן, פ"ד מ"א (3) 144).

72. מרבית השינויים שבוצעו בדירות הנתבעים שכנגד אשר פורטו בתביעה שכנגד (למעט הצבת המחסן וסגירת המרפסות), נמנים על השינויים אשר חל לגביהם סעיף 2(א) לתקנון המצוי אשר קובע כדלהלן:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה."

73. ככלל, לגבי שינויים אלו נדרשת הסכמת האסיפה הכללית.

74. על פי הפסיקה יכולת "הפגיעה" של בעל דירה ברכוש המשותף מצומצמת מאוד. כך נפסק כי "אין בעל דירה רשאי לעשות שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש משותף אלא אם כן קיבל הסכמת האסיפה הכללית ואין נפקא מינה אם הפגיעה היא קטנה או גדולה וניתנת לפיצוי נאות או לא" (ע"א 136/63 לוניהיים נ' שוורצמן פ"ד יז (3) 1722, 1725 (1963)). נקבע גם במפורש כי פגיעה ברכוש המשותף מצדיקה מתן צו עשה גם מבלי שיתלווה לפגיעה כל נזק ממשי (ע"א 515/65 רבובסקי נ' גלסברג פ"ד כ(2) 290 (1966) וראו גם ע"א 93/81 אליאס נ' שיפר פ"ד לז(2) 444 (1983) שאישר את ההלכות הנ"ל וע"א 395/74 לוי נ' סמואל פ"ד כט(2) 39 (1975)). אולם, גם פסיקה זו מסויגת בהתאם לעיקרון תום הלב החולש על כל תחומי המשפט, לרבות, על מערכת היחסים שבין בעלי דירות בבית משותף.

75. סעיף 14 לחוק המקרקעין קובע כי:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/341/2018, 8/450/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"בעלות וזכויות אחרות במקרקעין, אין בהן כשלעצמן כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי נוחות לאחר."

76. בע"א 810/82 זולבו בע"מ נ' זיידה פ"ד לו(4) 737, 740 (1983), וכן בע"א 782/70 רדומילסקי נ' פרידמן פ"ד כה(2) 523, 530 (1971) נפסק כי: בעלותו של שותף במקרקעין אין בה כשלעצמה "כדי להצדיק עשיית כל דבר ... הגורם נזק או אי נוחות לאחר" (סעיף 14 לחוק המקרקעין). הסייג השני קובע, כי הן הרוב והן המיעוט חייבים לפעול בדרך מקובלת ובתום לב (סעיפים 39 ו 61 (ב) לחוק חוזים (חלק כללי), התשל"ג – 1973). המיעוט והרוב אינם זרים זה לזה. עבותות של קניין מקשרים ביניהם. חוק המקרקעין מעניק לכל אחד מהם כוחות כלפי רעהו. בהפעלת כוחות אלה יש לנהוג בהגינות.

77. בהמשך הוחל במפורש עקרון תום הלב על מערכת היחסים שבין בעלי דירות בבית המשותף (ראו רע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף פ"ד מח (5) 550 (1994) וכן רע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון פ"ד נה(1) 199 (1999)).

78. פסק דין נוסף בו סקר בית המשפט באריכות את עקרון תום הלב בכלל ואת אופן כפיפותה של זכות הקניין לעקרון זה הוא ע"א 8661/10 נעמה נ' טורקיה פסקה 12 לפסק דינה של השופטת (כתוארה אז) חיות (פורסם בנבו, 19.2.2012) (להלן: "פרשת טורקיה"). מוצאת אני לצטט מפסק הדין את הקטע שלהלן שיפה הוא גם לענייננו אנו:

"חשוב להדגיש בהקשר זה כי הצורך בהחלת עקרון תום הלב על מקרה נתון נבחן באמת מידה אובייקטיבית. לכן, "אין נדרש כי בעל הזכות יפעל מתוך זדון או רוע-לב. די בכך שפעולתו אינה עולה בקנה אחד עם 'הסטנדרטים הערכיים הראויים של החברה הישראלית, כפי שבית המשפט מבין אותם מעת לעת' "(עניין רוקר, 277). ובמילים אחרות, בעל-דין המבקש לעמוד על זכויותיו מחויב מכוח עקרון תום הלב לעשות כן באופן הוגן ותוך התחשבות בציפיותיו המוצדקות ובהסתמכותו הסבירה של הצד האחר (ראו שם, 279. כן השו"ע ענין גנז, 404-408). יחד עם זאת, וככל שהדבר נוגע להגנה על זכות הקניין שומה על בית המשפט לעשות שימוש זהיר בשיקול- דעתו, וזאת בראש ובראשונה בשים לב למעמדה המיוחד של זכות זו כזכות חוקתית בשיטתנו המשפטית".

79. כל הנתבעים שכנגד טענו כי השינויים האמורים בוצעו בדירות לפני 12 שנים ויותר, ומרביתם אף בוצעו ע"י מי שהיו בעלי הדירות לפנייהם. האמור לא הוכחש ולא הופרך ע"י בכר, וגם מהתמונות שצורפו ניתן להתרשם כי מדובר בשינויים ותיקים.

80. בנסיבות אלו הרי שטענתם הבסיסית של בכר בכתב התביעה, לפיה הנתבעים שכנגד ביצעו את השינויים האמורים לא הוכחה.

81. כאמור לעיל, מרבית השינויים שבוצעו ברכוש המשותף הכוללים: פתיחת דלת, הוספת לבני זכויות בקיר חיזוני, הוספת מסתור כביסה, שינוי גודל חלונות והתקנת משטח דק בוצעו לפני שנים רבות. ויודגש, הנתבעים שכנגד טענו בתצהיריהם כי השינויים בוצעו בהסכמת כל בעלי הדירות בבית במועד ביצועם. בכר ויתרו על חקירת הנתבעים שכנגד לגבי הבניה האמורה, וגם לא טרחו להפריך טענה זו ע"י הבאתם לעדות של מי שהיו בעלי דירות בבית במועד בו בוצעו השינויים, אף לא את מקצתם. הנה כי כן, נותרה רק עדות בכר בעניין ומשקלה אינו רב, שכן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/341/2018, 8/450/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בכר לא יכולים היו להכחיש את טענת הנתבעים שכנגד בעניין שעה שהם כלל לא היו בעלי דירה בבית במועד בו בוצעו השינויים, ואף לא בשנים הסמוכות לאחר מכן.

על הימנעות בכר להזמין לעדות את יתר בעלי הדירות בבית קבע ביהמ"ש העליון בשורה של פס"ד כי:

"כלל הנקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נימנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לו לכך הסבר סביר ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכרעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה".

ראו בעניין ע"א 548/78 פלונית נ' פלוני, פ"ד ל"ה(1) 760, 736 (1980); ע"א 2275/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' רוזנברג, פ"ד מז(2) 605, 606 (1993).

82. לאור זאת, שיקולי הצדק ותום הלב מחייבים כי הנטל להוכיח העדרה של הסכמת האסיפה הכללית יוטל על בכר. ודאי אמורים הדברים שעה שמאז רכשו בכר את זכויותיהם בדירה חלפו כמעט שנתיים עד להגשת התביעה שכנגד, ואין עדות לכך שבכר הסתייגו או העלו טענה כלשהי כנגד השינויים מושא התביעה שכנגד. העובדה שהתביעה הוגשה רק כתביעה שכנגד, מועד הגשתה, כשנתיים לאחר שרכשו את הדירה, אופן הגשתה והתשומות המועטות שהופנו להוכחתה, מעיד על כך שהיא נועדה להוות משקל נגד לתביעה העיקרית במטרה להפעיל על התובעים לחץ לוותר על תביעתם, הא ותו לא. התרשמתי כי התביעה שכנגד לא הייתה באה לעולם אילולא הקדימו התובעים ותבעו אותם תחילה.

וראו בעניין את קביעת בית המשפט בפס"ד בן דוד כי הנטל להוכיח כי לא ניתנה הסכמת האסיפה הכללית חל על התובעים.

83. מן העדויות שנשמעו וכתבי הטענות עולה כי בעלי הדירות בבית לאורך השנים, וכן הבעלים הקודמים של דירת בכר לא נקטו בפעולה כלשהי בנוגע לשינויים האמורים. ההלכה קובעת כי **"על מנת להסיק ויתור מהתנהגות או ראיה אחרת, חייבת ההתנהגות להיות ברורה וחד משמעית ולהעיד על גמירות דעת, ידיעה והסכמה מלאה של הצד המוותר"** (ע"א 7388/97 עזבון משה שמיר ז"ל נ' דולב שמיר, פ"ד נג(1) 596 (1999)). בנסיבות דנן מצאתי להעדיף את גרסת הנתבעים שכנגד לפיה התנהלות בעלי הדירות לאורך למצער 12 שנים, כולל בכר בשנתיים עובר להגשת התביעה שכנגד, מלמדת על קיומה של הסכמתם לשינויים שבוצעו. ויודגש, לא נדרשת בהקשר דנן הסכמה פה אחד של בעלי הדירות, ודי בהחלטת האסיפה הכללית להתיר ביצועם של שינויים אלו.

84. לאור האמור, מוצאת אני להורות על דחיית התביעה בגין רכיבים אלו.

המרפסות שנסגרו-

85. סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין קובע לאמור -



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/341/2018, 8/450/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

71. (א) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות.

(ב) לא תתקבל החלטה כאמור בסעיף קטן (א) אם יש בה כדי לפגוע בזכויות בניה יחסיות של כל בעל דירה להרחבה לפי סימן זה.

(ג) בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין".

86. בפרשת אזרד נפסק כי הרחבת דירה כוללת בחובה גם הרחבתה של דירה באמצעות בנייתה של מרפסת לדירה. וכך נקבע בפסק הדין:

"לא מצאנו בלשון החוק כל אינדיקציה לכך ש'הרחבה' נועדה לפתור רק בעיה של מצוקת דיור אמיתית. גם אין רמז לכך שהרחבה לא יכולה להתייחס לבניית מרפסת, שהרי כבר נפסק שמרפסת היא חלק מדירה".

באמירה זו מתייחס בית המשפט למה שנפסק בע"א (מחוזי י-ם) 190/84 דיבון נ' הממונה על המרשם פ"מ תשמ"ה(2) 265 (1985). וראו חזרה על עמדה זו בעש"א (מחוזי חי') 3181-09-13 המאם נ' חורי (פורסם בנבו, 16.6.2014) ובעש"א (מחוזי חי') 50945-05-12 ברק נ' קרש (פורסם בנבו, 19.5.2013).

87. מכאן שבניית מרפסת הינה בבחינת הרחבת דירה אשר חלים עליה הוראות סעיף 71ב לחוק המקרקעין הן לעניין הרוב הדרוש והן לעניין ההסכמה קונסטרוקטיבית אשר חלה על מי שביצע בנייה דומה.

88. ספק בעיני אם סגירת המרפסות שהיו קיימות בדירות כמוהן כבנייתן של מרפסות חדשות יש מאין, שכן לא הובאו בפני כל ראיות לגבי מה היה קיים בדירות קודם לכן ומה סוג הסגירה שבוצעה. מכל מקום, ככל שסגירת מרפסות מהווה שינוי ברכוש המשותף, הרי שיחול בנושא הפרק הקודם של פסק דיני שדן בביצוע השינויים שבוצעו ברכוש המשותף, וקבע כי בנסיבות תיק זה ניתן להסיק קיומה של הסכמה של האסיפה הכללית, וככל שסגירת המרפסות עולה כדי הרחבת דירה אבחן להלן האם קיימת לנתבעים שכנגד הסכמה בשיעור הנדרש או האם ניתן לראות בבכר כמי שמנועים מלתקוף את סגירת המרפסות מהטעם שהם ביצעו "הרחבה דומה", כמשמעותה בסעיף 71ב(ג) לחוק.

89. נדל טענה בתצהירה כי בכר סגרו שתי מרפסות בדירתם, ראו סעיף 16 לתצהיר עדות ראשית מטעמה. בכר אישר בסעיף 44.7 לתצהירו כי סגר מרפסת אחת בדירתו באמצעות חלון אלומיניום. כן אישר בכר בעדותו כי מרפסת נוספת בדירה נסגרה טרם שרכש את הדירה, ראו עדותו בעמ' 5 לפרוטוקול הדיון מיום 17.12.19 שורות 24-28. לטענתו, סגירה של מרפסת בחומרים קלים אינה דומה לסגירה של מרפסת באמצעות קירות בלוקים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/341/2018, 8/450/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

90. מוצאת אני לדחות טענתו זו של בכר. ההבחנה בין סגירה באמצעות אלומיניום לבין סגירה באמצעות בלוקים היא מלאכותית. סגירה באמצעות בלוקים, וכמוה סגירה באמצעות אלומיניום או תריסים הופכת מרפסת פתוחה למרפסת סגורה, ולדידי, אין בטיב חומר הסגירה שוני משמעותי.

91. יתירה מכך, די בכך שנסגרו בדירת בכר שתי מרפסות כדי לראות בבכר כמי שביצעו "הרחבה דומה", ואין נפקא מינה לעניין סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין האם בכר ביצעו את הסגירה או הבעלים הקודם של הדירה עשה זאת. לאור האמור, הן מכוח הוראת סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין אשר רואה את בכר כמסכימים מכוח העובדה שביצעו "הרחבה דומה", והן מטעמים של חובת תום הלב מוצאת אני לדחות את טענות בכר בעניין המרפסות שנסגרו שעה שלא נסתרה טענת נדל כי בדירת בכר שתי מרפסות שנסגרו.

המחסן-

92. הכלל לפיו הצמדת רכוש המשותף לדירה פלונית דורשת את הסכמת כל בעלי הדירות קבוע בסעיף 62(א) סיפא לחוק המקרקעין הקובע כי: "... אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות".

93. במסגרת תיקון 18 לחוק המקרקעין (תיקון מס' 18), התשנ"ה-1995, ס"ח 1518 ביקש המחוקק למנוע מהמיעוט את זכות הוטו שהוקנתה לו מתוקף הוראת סעיף 62 לחוק כאשר מדובר בהרחבת דירה קיימת וזאת על מנת למצוא מזור לבעיות צפיפות המגורים (ראו את דברי ההסבר להצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 19) (שינוי הרוב הדרוש לשינויים ברכוש המשותף) התשנ"ה-1994 (ה"ח 2322).

94. כפי שנקבע בפס"ד גלמן, לעיל, בפסיקה נקבע כי "ויתור על זכות הנובעת מבעלותו בדירה בבית משותף בין שהמדובר בזכות ברכוש המשותף ובין שהמדובר בהסכמה לבניה (דהיינו ויתור על אחוזי הבניה) חייב להיות מפורש", ראו גם ה"פ 1266/03 (מחוזי ת"א) הורנשטיין נ' בליצר (פורסם בנבו, 25.11.2007) והפסיקה אליה הוא מפנה בפרקים 18-19 לפסק הדין.

95. המונח "הרחבה" מוגדר בסעיף 71א לחוק כ- "הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף". בספרו של המלומד אייזנשטיין בעמ' 223 נכתב כי- "כל הגדלה המהווה המשך טבעי של הדירה... יכולה להיחשב להרחבה, כגון, בניה על גג הבית, שהוא רכוש משותף וחיבור התוספת שנבנתה לדירה שמתחתיה. ההרחבה יכולה להיות גם אופקית, כגון בניית מרפסת או סגירתה, בניית פרגולה, בניה בחצר וחיבור התוספת שנבנתה לדירה קיימת בקומת הקרקע. התנאי להרחבה הוא כי ההרחבה תהא מתוך דירת המבקש". בהקשר זה נפסק זה מכבר כי תנאי לקיומה של הרחבה כהגדרת המונח בסעיף 71א לחוק הוא כי הצמדת החלק המסוים ברכוש המשותף צריך להיות בסמיכות פיסית לדירה המקורית, ראו ע"א 1462/10 עטיה נ' שגיא, (פורסם בנבו, 2.8.2012).

96. על פניו מהתמונה התחתונה בנספח יב' לתצהיר בכר, המחסן שנבנה בדירת חי אינו מהווה חלק בלתי נפרד מדירתם. באופן פיסי הוא אינו חלק מדירתם אלא מהווה יחידה נפרדת הממוקמת בחצר. במצב דברים זה הרי שאין מדובר ב"הרחבת דירה". אי לכך לא חל עליו סעיף 71ב ויש לקבל את הסכמה ברורה ומפורשת של כל בעלי הדירות לבניה מסוג זה. חי טענו בעדותם כי קיימת להם הסכמה כאמור אך לא הציגו אותה, לא במסגרת תצהירי עדות ראשית שהוגשו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/341/2018, 8/450/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מטעם הנתבעים שכנגד ולא במסגרת חקירתו הנגדית של חי במסגרתה נשאל על הסכמות אלו, ראו עדות חי בעמ' 6 לפרוטוקול הדיון מיום 26.6.19 שורות 3-8.

97. משלא הוכחו הסכמות ביחס למחסן שנבנה מוצאת אני להורות על הריסתו.

98. על אף האמור, ובשים לב לעובדה שלא הופרכה טענת חי כי מחסן זה קיים למצער 12 שנים, ואף בכר לא הלינו עליו מיום שרכשו את הדירה בבית ועד למועד הגשת התביעה שכנגד, מוצאת אני לקבוע שככל שבכר יעמדו על ההריסה, תנאי להריסה הוא שבכר יבצעו את ההריסה בכפוף לכל דין ועל חשבונם, לרבות הוצאות פינוי ההריסות מן המקום והשבת מצב החצר לקדמותה. בנוסף, אני מורה כי לבכר להקדים הודעה להריסה, באופן שלפחות 30 יום טרם הביצוע תשלח על ידם לחי הודעה בכתב בה יפורטו מועד ההריסה והפינוי.

סוף דבר-

99. התביעה העיקרית מתקבלת.

100. בכר יהיו רשאים להרוס את המחסן המשמש את חי בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 98 לעיל.

101. יתר רכיבי התביעה שכנגד נדחים.

102. אני מחייבת את בכר לשלם לתובעים, אצל באי כוחם, בגין התביעה והתביעה שכנגד הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 12,000 ₪.

103. אני מחייבת את חי לשלם לבכר, ביחד ולחוד, בגין התביעה שכנגד הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 2,500 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (15.5.18) ועד התשלום המלא בפועל.

העתק יישלח לצדדים.

ניתן היום, טו' בשבט תש"ף (10.2.20), בהעדר הצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין